

1500941-97.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500941-97.2020.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500941-97.2020.8.26.0510 - 2020/000238

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE PALMEIRO LEITE

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE PALMEIRO LEITE, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 31 de março de 2020, por volta das 16:30 horas, na Rua 19, com a Avenida 64, Recanto Paraíso, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 05 (cinco) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, e ainda guardava e tinha em depósito outras 15 (quinze) porções da mesma substância entorpecente, totalizando com aquelas outras peso líquido aproximado de 48,4 gramas, e outros 60 (sessenta) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 16,1 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 16/19, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 18 de novembro de 2020.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, operando-se, ainda, o perdimento da importância em dinheiro apreendida. Já ilustre Defensora Pública, inicialmente haver dúvida sobre a materialidade do delito, dada as divergências sobre a natureza do entorpecente apreendido, reclamou a absolvição nos termos do disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. No mérito, sustentou insuficiente a prova produzida, a determinar por aqui a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, pugnou fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com fixação de regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Requereu, por fim, a restituição da quantia apreendida em poder do acusado. Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque trazia consigo e ainda guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão (fls. **), no laudo de constatação (fls. 16/19) e no auto de exame químico-toxicológico encartado as fls. 85/86, com resultado positivo para cocaína. Sustenta-se que haveria dúvida sobre a natureza do entorpecente apreendido, assim em razão do que consta do depoimento dos policiais militares (fls. ***). No entanto, em juízo, esclareceram que houve equívoco possivelmente de digitação, ambos afirmando parte do entorpecente não se tratava de maconha, mas de uma substância mesclada, com a utilização de cocaína, esta divergência não suscitando dúvida séria sobre o que efetivamente apreendido, como consta no auto de exibição e apreensão e constatação, de modo a afastar a materialidade.

Controverte-se sobre a posse da totalidade do entorpecente apreendido e sua destinação mercantil.

Ouvido em juízo, o acusado negou a prática do delito, observando que realmente foi abordado no local dos fatos, onde acabara de adquirir cinco porções de cocaína, negando estivesse por lá realizando o comércio ilícito de entorpecentes, como também que soubesse da existência, nas proximidades de onde abordado, do restante da droga apreendida.

Todavia, a versão deduzida pelo acusado, foi contrariada pela prova produzida.

Os policiais militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o acusado agachado revirando um monte de areia. Quando ele notou a aproximação, tentou empreender fuga, mas foi logo em seguida abordado, apreendendo-se em poder dele cinco porções de uma substância mesclada, considerada como cocaína, além de oitenta e nove reais em dinheiro. Realizada uma busca no ponto onde se encontrava anteriormente, no monte de areia sobre o qual estava agachado, encontraram sessenta eppendorfs contendo cocaína, além de quinze outras porções semelhantes àquelas que foram apreendidas em poder do acusado, tendo este então admitido a realização do comércio ilícito.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no

desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorреitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, considerando que o acusado se encontrava em conhecido local de comércio de entorpecentes, tendo sido surpreendido no momento em que revirava um monte de areia, por isto sendo realizada uma busca neste local, onde apreendidos sessenta eppendorfs contendo cocaína e ainda quinze porções de uma outra substância semelhante àquelas encontradas em seu poder, admitindo informalmente o tráfico no local, possível a conclusão de que o entorpecente realmente estava destinado ao comércio ilícito, não obstante a condição de usuário.

De outra parte, e isto foi reconhecido pelo Ministério Público, há dúvida sobre se o acusado estava dedicado efetivamente à disseminação do entorpecente ou se se tratava de situação episódica, marcada pela condição de usuário, possibilitando, portanto, o reconhecimento da figura privilegiada, diante da possibilidade da incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Deixa-se, ainda, de impor a pena de perdimento sobre a quantia em dinheiro apreendida, porquanto não houve indicação de que, naquele momento, decorresse da atividade ilícita.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Por fim, considerando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo o acusado primário e não sendo integrante de organização criminosa, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda.

Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa". Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de

indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda.

Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Desta forma, pelos princípios acima indicados, ressaltando o posicionamento contrário deste julgador, a fim de evitar decisões contraditórias, que mais se potencializam em sede de jurisdição que alcança território mais reduzido, evidenciando desigualdade bastante gravosa, cumpre a este juízo também se alinhar à jurisprudência do Pretório Excelso.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado MATHEUS HENRIQUE PALMEIRO LEITE à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se oportunamente a restituição dos valores apreendidos.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA